

1500966-51.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... pena de prisão quando era menor, por tráfico de drogas, e ficou dez meses internado, saindo há três meses. Sobre os fatos disse que desconhece a acusação de tráfico de drogas, pois pegou a moto do "Paraná", seu colega, para buscar "pedra", já que a maconha era sua. Disse que no momento em que estava voltando, os policiais, que já o conheciam, mas nunca tomou enquadrado desses ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500966-51.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500966-51.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICAEL JOSAFÁ SILVA BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra MICAEL JOSAFÁ SILVA BARBOSA, qualificado à fl. 07, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos 33, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de novembro de 2021, por volta de 19h30min, na Rua Manoel Nunes Bitencourt, n.º 226, Bairro Jardim Marisa, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, MICAEL JOSAFÁ SILVA BARBOSA, qualificado à fl. 07, transportava e mantinha em depósito para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 02 (dois) invólucros contendo aproximadamente 115,09g (cento e quinze gramas e nove decigramas) de maconha; 01 (um) invólucro contendo aproximadamente 65,04g (sessenta e cinco gramas e quatro decigramas) de

maconha e, por fim, 02 (dois) invólucros contendo aproximadamente 1,97g (um grama e noventa e sete decigramas) de cocaína na forma de "crack", todos acondicionados em material plástico, consoante auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) e laudo pericial definitivo de fls. 104/106. Segundo apurado, o denunciado adquiriu referidos entorpecentes e terceiro não identificado e os transportava em uma motocicleta para posteriormente comercializá-los. No dia dos fatos, o denunciado trafegava com a motocicleta Honda CG/Titan, placa EKH-3J85, cor vermelha, quando policiais militares o avistaram. Os policiais detinham notícia do prévio envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas e deliberam abordá-lo, eis que já havia logrado evadir em situações anteriores. Após breve perseguição, o denunciado foi abordado no local dos fatos e submetido a busca pessoal, sendo localizado nos bolsos de sua bermuda 02 (dois) invólucros contendo aproximadamente 115,09g (cento e quinze gramas e nove decigramas) de maconha e 02 (dois) invólucros contendo aproximadamente 1,97g (um grama e noventa e sete decigramas) de cocaína na forma de "crack". Com a anuência de MICAEL JOSAFÁ, os policiais rumaram em direção do domicílio dele, onde apreenderam 01 (um) invólucro contendo aproximadamente 65,04g (sessenta e cinco gramas e quatro decigramas) de maconha no quarto do denunciado, além de diversos fragmentos plásticos comumente utilizados para preparar entorpecentes e um faca com resquícios de drogas. Considerando a apreensão dos entorpecentes em razoável quantidade e variedade e as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, está evidenciado que as substâncias entorpecentes apreendidas tinham como destino a mercancia ilícita. Há notícia nos autos quanto ao envolvimento do denunciado com a mercancia de entorpecentes durante a adolescência - fls. 55/59. Requisitou-se exame pericial do aparelho celular do denunciado e demais objetos apreendidos - fls. 101/102.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 152/171), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 117/118), o despacho de fls. 200/204, de 14 de janeiro de 2022, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 254/255), pediu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor Público (fls. 245/253), requer a absolvição do réu, por ausência do elemento típico constante do tipo penal, que confirme a traficância, já que ter em depósito, transportar ou trazer consigo, não evidenciam o tráfico de drogas, mas se confundem com o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, assumindo o réu, em Juízo, que a droga era para seu consumo próprio.

Também requer a absolvição do réu por ausência de tipificação quanto a mercancia imputada na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal. Requer ainda, o reconhecimento da menoridade relativa do réu, a sua confissão espontânea em Juízo, e ainda as circunstâncias sociais e pessoais, indicam uma menor reprovabilidade, bem como pelo não acolhimento dos antecedentes criminais enquanto menor de idade, portanto, o réu é primário e de bons antecedentes, devendo a pena ser fixada no mínimo legal, substituindo a pena corporal por restritiva de direitos, reconhecendo o tráfico privilegiado, bem como que possa recorrer em liberdade, e por fim, requer que seja desclassificada a conduta do réu para o crime de posse ilegal de drogas para consumo pessoal.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls.

13/14; pelo relatório de investigação policial de fls. 22/35; pelas fotografias de fls. 15/25; pelo laudo de constatação preliminar de fls. 28/30; pelo laudo químico toxicológico de fls. 104/106, atestando - Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0035545 ) Descrição: 1 (um) invólucro(s) plástico(s) encerrando 2 (duas) porções de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 120,77 grama(s) - cento e vinte gramas e setenta e sete centigramas. Massa Líquida: 115,09 grama(s) - cento e quinze gramas e nove centigramas. Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0035544 ) Descrição: 1 (um) invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 70,69 grama(s) - setenta gramas e sessenta e nove centigramas. Massa Líquida: 65,04 grama(s) - sessenta e cinco gramas e quatro centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Laudo pericial no aparelho celular de fls. 179/195; pelo laudo pericial em objetos apreendidos de fls. 197/199, que detectou - Item 1 (Acondicionado sob o lacre 018406 ) Descrição: 01 (uma) faca, usada, em estado regular de conservação, da marca "TRAMONTINA", dotada de lâmina pontiaguda e de gume afiado, com o cabo confeccionado em material sintético de cor AZUL. A peça examinada acima, pelas características apresentadas e no estado em que se encontra, além das finalidades precípuas a que se destina, pode ser usada com eficácia para fracionamento de substâncias entorpecentes. A peça foi submetida à lavagem química para análise. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e, foi(ram) observada(s) presença da(s) seguinte(s) substância(s): TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); e COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). Item 2 (Acondicionado sob o lacre 018406) Descrição: Um invólucro(s) plástico(s) encerrando aproximadamente quarenta quatro embalagens plásticas transparentes com cada unidade dotada de dimensões aproximadas de 4x23,5 cm. A peça foi submetida à lavagem química para análise. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e, foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, o PM Amauri Aparecido Rodrigues, sob o crivo do contraditório declarou que estavam em patrulhamento pelo Bairro Alvorada, depararam-se com o réu pilotando uma CG Titan Vermelha, placas EKH3J85, Mercosul, e ao avistar a viatura, empreendeu fuga, e acompanhado por alguns quarteirões, momento em que foi abordado. Em revista pessoal foi localizado em suas vestes uma porção grande maconha no bolso da bermuda, mais uma porção pequena de macocha embalada em plástico filme, duas pedras de crack, um aparelho celular Motorola, e R\$ 59,50. Indagado quanto a motocicleta e os objetos, disse que a moto emprestou de um vizinho, tendo se deslocado até o Jardim Sumaré, local onde teria comprado a maconha e crack, pagamento pelo crack R\$ 70,00 e R\$ 120,00 pela maconha, para posteriormente fracionar e vende-la na linha férrea. Indagado se na residência havia mais droga, negou, mas franqueou a entrada. Em sua residência na Rua Mariquinha Cunha, 1010, Vila Verinha, onde em buscas na residência, encontramos dentro do guarda-roupas, mais uma porção de maconha embalada em plástico de cor verde, uma faca de serra com resquícios de maconha e várias embalagens plásticas transparentes, próprios daquelas para embalar geladinho. Nesse momento, compareceu no local o proprietário da moto dizendo que havia emprestado para Micael, mas não revelou o motivo. Dado ciência da ocorrência e que Micael seria conduzido até a Participativa juntamente com a moto, pois ele estaria envolvido em ocorrência de tráfico. Com Micael, diante de toda a droga encontrada e demais objetos foi dada voz de prisão e conduzido à Participativa. Novamente compareceu na Delegacia o suposto dono da moto, mudando sua versão anterior, dizendo que emprestou a moto para Micael em troca de droga, pois era

usuário. Afirmar que já havia denúncias diretamente à equipe sobre seu envolvimento com o crime de tráfico, inclusive o acusado já se evadiu de outras tentativas de abordagem da Polícia Militar. Diz que foi o próprio acusado que deu autorização para ingressar em sua residência, e consta a autorização no BOPM, e não foi feito nenhum registro de áudio e vídeo. O BOPM é confeccionado durante a apresentação da ocorrência. Diz que é subjetivo a quantidade de atendimento que faz durante o mês com relação a esse crime, não tem uma média de ocorrência, pois tem missões, viagens, não sabe informar a quantidade de ocorrência que participa.

O PM Douglas Antonio Moraes Barga, sob o crivo do contraditório declarou que estavam em patrulhamento pelo Parque Alvorada quando se depararam na Rua João Salvador, com o Micael conduzindo uma motocicleta de cor vermelha e na tentativa de abordagem, empreendeu fuga por diversas ruas do bairro, conseguindo abordá-lo na Rua Manoel Nunes Bitencourt, 226. Durante as buscas pessoais foi localizado com ele, parte de um tijolo de maconha, uma porção de maconha, duas pedras de crack na linha da cintura, e um celular e a quantia de R\$ 59,50. Indagado sobre as drogas, disse que havia comprado há pouco tempo no jardim Sumaré e pago a quantia de R\$ 120,00 pela maconha e R\$ 70,00 pelo crack, para posteriormente vender na linha férrea, onde há grande concentração de usuários. Sobre a motocicleta disse que emprestou de um amigo e indagado se em sua residência havia mais entorpecentes, disse ele que não havia e franqueou a entrada da equipe. Dentro da residência em seu guarda-roupas em seu quarto, foi localizado entre suas vestes, mais uma porção grande maconha que daria para ser fracionada em diversas outras porções, uma faca com resquícios de entorpecente e embalagens plásticas, sendo dado voz de prisão a ele e conduzido a Delegacia de Polícia para lavratura do flagrante. Confirma que já havia várias denúncias contra ele, já que é bastante conhecido da Polícia pela prática do tráfico de drogas, e que esse dia tentou fugir da guarnição, já conseguiu fugir da abordagem de outra viatura antes do dia 11 de novembro, e não conseguiram pegá-lo. Afirmar que foi o próprio Micael que autorizou o ingresso em sua residência e que foi registrado somente no BOPC. As denúncias vêm diretamente para a equipe já que fazemos bastante patrulhamento na área de atuação do réu, e alguns usuários passam informações para a equipe, bem como outros policiais da rádio patrulha que compartilham essas informações e por vários transeuntes que também passam informações para a Polícia.

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

“PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))”.

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que “como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” - “Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,

age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))”

Observe-se que o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento” (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que “em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário” (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que “pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis” (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278).

A testemunha Cristiane Ferreira Santana, sob o crivo do contraditório, declarou que conhece o réu, mas não viu o réu ser preso e nem a Polícia entrar em sua residência, e sabe que ele trabalha com o pai, e não sabe se ele tem envolvimento com o tráfico e nem se é usuário de drogas. Sabe que a relação do réu com a mãe de amorosidade, como também com a esposa. Sabe que ele tem um filho com a esposa, que ele cuida da criança.

A testemunha Marina Eunice de Campos Dias Silva, sob o crivo do contraditório, declarou que é apenas conhecida do Micael, mora próximo, desde criança. Afirma que não o viu ser preso e nem a Polícia ingressar em sua residência. Sabe que ele é casado, mas não no papel. Sabe que ele cuida bem da família, que é bom pai e marido. Sabe que ele trabalha com o pai dele como auxiliar de pintura. Sabe que ele usa maconha, que via na rua, que usa desde pequeno, desde que o conhece. Sabe que enquanto menor era traficante, depois que saiu, disse que iria mudar de vida e arrumar um serviço. Sabe que a relação do réu com a mãe, é tranquilo, é muito carinhoso, nunca viu ele desrespeitando e nem respondendo para sua mãe. Disse que ele frequenta a igreja, somente quando a mãe mudou de igreja que ele não foi mais. O réu Micael Josafá Silva Barbosa, em seu interrogatório declarou que já foi preso e cumpriu pena de prisão quando era menor, por tráfico de drogas, e ficou dez meses internado, saindo há três meses. Sobre os fatos disse que desconhece a acusação de tráfico de drogas, pois pegou a moto do “Paraná”, seu colega, para buscar “pedra”, já que a maconha era sua. Disse que no momento em que estava voltando, os policiais, que já o conheciam, mas nunca tomou enquadro desses policiais, e quando lhe viram já parou a moto. Que não correu, nem empreendeu fuga. Disse que estava com a droga, maconha e crack, e que a moto era de seu amigo. Afirma que chegaram em sua casa e ninguém estava em casa, quando os policiais disseram que iam estourar a porta, então disse que sua mãe estava na igreja e a casa estava trancada e não tinha a chave. Que não sabe como os policiais entraram em sua residência, não sabe se sua mãe deixou a chave na janela, não sabe se eles acharam, pois ficou na viatura e não sabe como eles entraram. Que encontraram mais droga dentro de sua residência, e era de sua propriedade, e estava no seu guarda-roupas. Afirma que

tinha essa grande quantidade e que era próximo ao final do ano e resolver pegar tudo isso de drogas, pois fuma pedra com maconha, chamado de mesclado. Que fuma desde criança, mas não fica mostrando para as pessoas que fuma droga, nem mesmo para sua mãe, para não chateá-la. Não acompanhou as buscas em sua residência, pois ficou na viatura, algemado. Estava trabalhando, mas são vários locais que eles pegam para fazer serviço, perto do centro, e o último disse que era perto do parque do povo. Disse que frequenta a igreja.

A negativa dos réus não pode ser acolhida, posto que além de não ser confirmada pela prova dos autos, está desmentida por ela, que demonstra de forma segura que os fatos se passaram como narrados na denúncia e a autoria dele pelo réu, além disso, não conseguiu justificar a apreensão do dinheiro e quanto a droga, apenas limitou-se a dizer que era para seu consumo próprio, pois chegaria o final de ano e resolveu comprar uma grande quantidade, mas nenhuma prova da sua alegação trouxe aos autos, caindo em total descrédito diante de tudo o que foi amealhado aos autos. Também não prospera a alegação de que a droga era para consumo próprio, já que também foi desmentida pela prova dos autos, vez que usuários e transeuntes já vinham relatando o tráfico de drogas naquela região, já que ficou evidentemente demonstrado que, desde a adolescência vinha praticando o comércio espúrio de tráfico de drogas, e cansados da atividade criminosa do réu, acabam denunciando, mesmo que seja de difícil identificação, o que veio a ser claro que, por não encontrar justificativas para a droga, o dinheiro, os demais objetos usados para fracionar e embalar drogas, encontradas no imóvel usado ponto de tráfico de drogas, portanto, sua versão é fantasiosa e restou isolada diante de todo o conjunto probatório coligido aos autos.

Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta do réu, não só pela apreensão das drogas nos dias dos fatos, mas pela ocorrência dos fatos como informado através da Polícia Militar; não só da droga, mas também do dinheiro que portava, num total de R\$ 59,50 (cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), em notas diversificadas, típicas do recebimento de usuários na venda de drogas, o que por si só, não denotam o crime de tráfico, mas aliada aos demais objetos e a droga, um tijolo de maconha que acabara de receber de outro traficante, que pesou cerca de 115,14 g e uma outra de 65,03 g de maconha, além de duas pedras de crack, que renderia muitas porções de maconha fracionadas para a venda.

Além disso, havia embalagens usadas para acondicionar droga para a venda a usuários. Por tudo isso, demonstrada, a saciedade, a atividade espúria realizada pelo réu.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher a negativa do réu e nem o pedido de desclassificação para o delito posse para consumo pessoal, já que é evidente a sua condição de traficante do réu, até porque, foi dito por ele mesmo no interrogatório, na presença de seu advogado, que estava internado por dez meses pelo crime de tráfico de drogas, e que havia saída há apenas três meses, tudo a evidenciar que não foi suficiente o tempo de internação para que entendesse o prejuízo da sua ilicitude pudesse trazer para sua vida. Ademais, registra mais de dez ações por atos infracionais, muitos deles por tráfico de drogas.

A testemunha Marina Eunice, em Juízo, e sob o crivo do contraditório, disse que o réu é seu conhecido desde pequeno e sabe que ele usa droga, que era traficante enquanto menor, mas que depois disse que mudaria de vida e arrumaria um emprego. Suas palavras são eloquentes e confere maior veracidade aos fatos imputados ao réu, portanto, é nítida a condição de traficante do réu, já que muito conhecido no bairro e na área de atuação dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, munidos de várias denúncias anônimas e outras de usuários de drogas, que o réu Micael Josafá faz do crime de tráfico de drogas o seu meio de subsistência. Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar

que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal. Importante ressaltar, inclusive, que tanto com o réu como escondido em sua residência, ambas demonstram a principal destinação das drogas.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos."

(Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745);

"Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Diante de tudo que foi amealhada aos autos, impossível acolher o pedido da Defesa do réu para desclassificação do delito de tráfico para o de porte de droga para consumo pessoal, já que, ao contrário do que alega a defesa, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas, procedendo a ação penal como pedido na denúncia.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizara conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Por tudo isto é que procede a ação penal e é de rigor a condenação do réu por tráfico de drogas.

Passo a dosagem da pena.

Na dosagem da pena levo em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, que não lhes são favoráveis, especialmente, por ter ele mesmo confessado, que desde a menoridade já respondeu por ato infracional e apreendido, cumprindo medida socioeducativa de internação pelo grave fato antissocial de tráfico de drogas, entre outras tantas infrações (fls. 55/59), fixo a pena base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), fixando a pena base em 5 (cinco) anos e 10

(dez) meses de reclusão e a pagar 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Indispensável é no caso, avaliar a contemporaneidade do ato infracional com o presente processo, como prova do engajamento criminal do réu com o relacionamento com atividade criminosa ou que integre organização criminosa, vez que o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fala em “não se dedique” e “não integre”, ou seja, no tempo presente, dessa forma, é condizente com a atual situação do réu Micael Josafa, que logo após completar a maioridade, voltou a delinquir e infringir a mesma norma penal contida no artigo 33, da referida lei, ou seja, não foi suficiente e adequada para que pudesse se ressocializar e não voltar a praticar crimes.

Nesse sentido, é a recente decisão em Embargos de Divergência em Recurso Especial sob nº 2021/0012980-3, pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Consoante o § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos. 2. Na esfera da Lei n. 8.069/1990, as medidas socioeducativas aplicadas em resposta a ato infracional cometido por adolescente possuem o objetivo de responsabilização quanto às consequências lesivas do ato, a integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como a desaprovação da conduta infracional (art. 1.º, § 2.º, incisos I, II e III, da Lei n. 12.594/2012 - SINASE). 3. No entanto, apesar de a medida socioeducativa, impositiva e preponderantemente pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que não configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus antecedentes. Nessa medida, é incompatível considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, obstando a minorante, equiparando a conduta a crime hediondo e recrudesendo a execução penal. 4. Vale dizer, o registro da prática de fato típico e antijurídico por adolescente (inimputável), que não comete crime nem recebe pena, atingida a maioridade penal, não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação a atividades criminosas, e produzir amplos efeitos desfavoráveis na dosimetria e execução da pena. 5. No caso concreto, foi tida por inidônea a fundamentação que fez alusão genérica ao histórico infracional para concluir pela comprovação da dedicação às atividades criminosas, sobretudo porque nenhum outro dado foi extraído do conjunto probatório para respaldar a conclusão de que os agentes vinham se dedicando à atividade criminosa, o que tampouco foi possível identificar a partir da quantidade não expressiva de entorpecente. 6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressaltado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. 7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.” (EResp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 04/10/2021).

No mesmo sentido já vinha decidindo acerca da matéria a 5ª Turma do S.T.J.:



"Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no Recurso Especial n. 1873094/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020).

Muito embora, o Supremo Tribunal Federal, que ainda não decidiu unanimemente acerca da matéria, somente pelas Turmas daquela Corte, que pela 1ª Turma em decisão monocrática do Min. Luiz Fux, entende pelo afastamento da minorante do §4º, do artigo 33, da Lei em comento, senão vejamos o precedente abaixo colacionado: [...]. Na espécie, o benefício do tráfico privilegiado foi afastado em razão de a paciente se dedicar a atividade criminosa, o que restou demonstrado do amplo conjunto probatório dos autos. Quanto ao tema, o Tribunal a quo assentou que "o histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menor, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de drogas, justificam a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas". Desta sorte, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. [...] Ex positis, NEGOU SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. (RHC n. 180.509, Rel. Ministro Luiz Fux, monoc., DJe 6/2/2020). Portanto, os atos infracionais podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa, o que ficou amplamente demonstrado nos autos. Nesse diapasão, é de se reconhecer que a razão de ser do chamado "tráfico privilegiado", consiste em punir com menor severidade aquela que vem a ser surpreendido pela primeira e única vez, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida.

Na segunda fase ausentes quaisquer circunstâncias agravantes, reconheço a menoridade relativa do réu, que possuía menos de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, promovo a diminuição no patamar de 1/6 (um sexto), conforme dispõe o artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que a torno definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e a pagar a multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Ante a condição financeira do réu e as causas que influenciaram na fixação da pena corporal fixo a pena de multa no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 2º., § 1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei n.º 11.464/06, o que não fere qualquer princípio constitucional, uma vez que está em conformidade com o disposto no art. 5º, incs. XXXIX, XLVI e XLIII, da Constituição Federal.

Ademais, é incompatível outro regime, pois se trata de crime equiparado a hediondo, portanto, de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade, inclusive, se dedica integralmente ao tráfico de drogas, fazendo do crime seu estilo de vida, conforme ficou exaustivamente demonstrado nos autos e por seus antecedentes.

Inviável qualquer substituição diante do montante da pena, pelos mesmos motivos acima expostos.

Incabível o "sursis", por não preencher os requisitos do artigo 77, inc. II, do Código Penal e por ser incompatível com o regime semiaberto previsto na Lei 8072/90.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu MICAEL JOSAFÁ SILVA BARBOSA, RG: 52398360, CPF: 402.918.658-01, nascido em 01/10/2002, natural de Presidente Prudente - SP, filho de JOSE BENTO BARBOSA NETO e GISELE SILVA BARBOSA, a cumprir a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e a pagar a multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na

denúncia, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Ainda sobrevivem os motivos da decretação da prisão preventiva do réu nestes autos e por ter ele respondido todo o processo preso, agora imponho-lhe a obrigação de recolher-se à prisão para poder apelar desta sentença.

INCONTINENTE, comunique-se a sentença no presídio que ele se encontrar.

INCONTINENTE, comunique-se esta sentença aos autos do Habeas Corpus nº 2285917-37.2021.8.26.000, que figura como paciente Micael Josafá Silva Barbosa, em trâmite perante a E. 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo como Relator Desembargador Bueno de Camargo.

Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Decreto a perda em favor da UNIÃO de todo o numerário e do veículo apreendido nos autos, posto que oriundo e usados para a prática do crime do tráfico de drogas.

Determino a imediata destruição do aparelho celular e dos demais objetos apreendidos nos autos posto que utilizados para o tráfico conforme demonstrou a perícia neles realizada.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA